

1008531-30.2020.8.26.0302
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Acumulação de Cargos
Magistrado: Daniela Almeida Prado Ninno
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 3ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 16/02/2022

... específicos na apuração de crimes de tráfico de drogas, identificação de pessoas e coisas, análise de câmeras de segurança e celulares para identificação da ocorrência de crimes, além de diversos outros trabalhos investigativos específicos. Alega que sua atividade de rotina é especificamente investigativa e não de dirigir viaturas, executar manutenção preventiva ou outras atribuições ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
3ª Vara Cível
Avenida Rodolpho Magnani, sn, Jaú - SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1008531-30.2020.8.26.0302 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1008531-30.2020.8.26.0302
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Acumulação de Cargos
Requerente:
Osvaldo Domingues Figueiredo
Requerido:
Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Almeida Prado Ninno

Vistos.

OSVALDO DOMINGUES FIGUEIREDO move ação indenizatória de diferenças salariais por desvio de função em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando que é servidor público estadual concursado para o cargo de agente policial. Aduz que sua nomeação ocorreu através do Decreto nº 44.448/1999, publicado no Diário Oficial do Estado em 12 de janeiro de 2000. Afirma que o cargo foi criado através da Lei Complementar Estadual nº 494/1986, que extinguiu o cargo de motorista policial e instituiu o cargo de agente policial. Narra que as atribuições do cargo foram estabelecidas pelo artigo 1º da Portaria DGP nº 12/1987. Argumenta que a mesma portaria dispôs que seria vedada a incumbência ao agente policial de atividades de outras carreiras policiais. Alega que o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo houve por bem proibir a atribuição de serviços diversos aos inerentes a seu cargo. Aduz que vem exercendo funções específicas da carreira de investigador de polícia, muito embora sua remuneração seja inferior a tal cargo. Afirma que exerce rotineiramente todas as atividades precípuas de investigação policial, típicas do cargo de investigador. Narra que os boletins de ocorrência acostados aos autos revelam que exercia atividades de busca e apreensão, condução coercitiva, condução de pessoas presas, dentre outras funções típicas de investigador de polícia. Argumenta que é responsável por trabalhos investigativos específicos na

apuração de crimes de tráfico de drogas, identificação de pessoas e coisas, análise de câmeras de segurança e celulares para identificação da ocorrência de crimes, além de diversos outros trabalhos investigativos específicos. Alega que sua atividade de rotina é especificamente investigativa e não de dirigir viaturas, executar manutenção preventiva ou outras atribuições correlatas. Aduz que suas atividades, desde sua nomeação e posse, se referem exclusivamente a trabalhos investigativos, motivo pelo qual resta a caracterização de desvio de função. Afirmar que faz jus à diferença entre o vencimento dos cargos. Narra que, considerando os últimos cinco anos, faz jus ao montante de R\$ 81.269,98, além de valores que sobrevierem no curso do processo. Pede a procedência da ação com a condenação da requerida ao pagamento do valor de R\$ 81.269,98, além das parcelas que se vencerem no curso da ação e ao pagamento da diferença salarial entre os cargos de agente policial e investigador de polícia, enquanto perdurar o desvio de função. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

Houve decisão determinando ao autor a juntada de documentos, para aferição do pedido de justiça gratuita.

O requerente juntou documentos.

Deferiu-se ao autor os benefícios da gratuidade processual.

Em contestação, a requerida alega que não há diferenças salariais a serem pagas a qualquer título. Aduz que as atividades da Polícia Civil do Estado de São Paulo são organizadas, precipuamente, pela Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Lei Complementar nº 207/1979). Afirmar que, referida lei, prevê que o cargo de agente policial integra o quadro da Secretaria de Segurança Pública como integrante da Polícia Civil. Narra que as atribuições dos diversos cargos da Polícia Civil estão definidas em normas regulamentares. Argumenta que a Portaria DGP nº 30/2012 estabeleceu quais atividades são comuns a todos os integrantes da Polícia Civil, inclusive ao cargo de agente policial. Alega que o edital do concurso prestado pelo autor se referiu expressamente à tal portaria. Aduz que a alínea "e" do artigo 1º da portaria dispõe que é obrigação funcional de todos os policiais civis, independentemente da carreira que ocupam, cumprirem diligências e/ou requisições da autoridade policial, devendo elaborar os relatórios respectivos. Afirmar que, em todas as atividades desempenhadas pelo autor, não há que se falar em desvio de função. Narra que é vedada qualquer investidura em carreira diversa daquela em que o servidor ingressou por concurso. Argumenta que o pedido não pode ser acolhido sem que se admita, previamente, uma equiparação entre os cargos em análise, o que não pode ocorrer, uma vez que o ordenamento jurídico não prevê sua concessão. Alega que seria lícito ao autor recusar obedecer ordem que não correspondia ao exercício da função para a qual havia sido admitido. Aduz que, se eventualmente permaneceu em desvio de função, tinha ciência da irregularidade de sua situação, não podendo agora reclamar diferenças decorrentes de tal atuação. Afirmar que o deferimento do pedido inicial gerará afronta ao princípio da legalidade, por impor ao réu condenação não prevista por qualquer legislação substantiva, o que implicará em indevida ingerência do Poder Judiciário nos assuntos da Administração Pública. Pede a improcedência da ação.

O autor impugnou a contestação.

Houve decisão designando audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência, foi ouvida uma testemunha do autor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação procede parcialmente.

O requerente alega que é servidor público concursado para o cargo de agente policial. Afirmar que realiza atividades típicas de investigador de polícia, embora receba remuneração inferior a tal cargo. Pede o recebimento das diferenças salariais entre os dois cargos dos últimos cinco anos e das parcelas que se vencerem ao longo do processo, enquanto perdurar o desvio de função.

Os documentos de folhas 13/15 demonstram que o requerente, por meio de concurso público, foi contratado para o cargo de agente policial, realizando, a partir de 05 de janeiro de 2000, a academia de polícia.

A testemunha Eduardo disse, em depoimento, que é investigador de polícia. Aduz que

trabalhou com o requerente desde 2017 até há um ou dois meses atrás. Afirmar que foi transferido de unidade. Narra que, durante tal período, o requerente trabalhava na parte de investigação, realizando campanhas, relatórios de investigação, cumprimento de mandados de busca e de prisão. Argumenta que, em praticamente todo o serviço realizado, o requerente estava junto. Alega que o requerente realizava tais atividades sozinho ou junto com os demais policiais. Aduz que os mandados de prisão são cumpridos em dupla. Afirmar que, quanto às atividades de diligência de investigação, o requerente realizava algumas sozinho, como campanhas e relatórios sugerindo o pedido de mandado de busca. Narra que, outras vezes, tais atividades eram realizadas em conjunto com os investigadores de polícia. Argumenta que, quanto a policiamento preventivo, geralmente são realizados em pelo menos duas pessoas. Alega que não se recorda se o requerente fazia atendimento ao público. Aduz que o requerente chegou a registrar boletins de ocorrência. Afirmar que o requerente fazia transporte de coisas relacionados à ocorrência, do local do fato até a delegacia e da delegacia até o Fórum. Narra que o requerente fazia acompanhamento de presos da cela para interrogatórios, procedimentos, cadeias e Fóruns. Argumenta que, geralmente, os mandados são cumpridos em no mínimo duas pessoas. Alega que, além do requerente, havia outro agente policial lotado na delegacia em que trabalhavam juntos. Aduz que, tais atividades, como campanhas e diligências para levantar endereço e realizar filmagens, o requerente já chegou a fazer com outro agente ou o escrivão, fora os investigadores. Afirmar que, na prática, agente policial e investigador de polícia realizam as mesmas atividades, não havendo praticamente distinção.

A prova oral colhida demonstra que o requerente exercia funções típicas investigativas, como campanhas, relatórios de investigações, cumprimento de mandados. Ainda, a testemunha relata que, na prática, não há diferença entre as atividades desempenhadas por um agente policial e um investigador de polícia. Ainda, os documentos anexados com a inicial às folhas 30/127 dão conta da confecção de ofícios de informação e relatórios pelo requerente, a presença do autor como testemunha em processos criminais e como condutor em boletins de ocorrência. Ora, a remuneração do servidor deve guardar relação direta com os serviços prestados, sob pena de se permitir enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. O fato é que a Administração foi a responsável pelo desvio de função. Foi ela quem se valeu de seu poder hierárquico, determinando ao requerente que executasse funções diversas daquelas para as quais foi contratado sem que, todavia, o remunerasse de forma adequada para as novas funções. Com efeito, conclui-se que realmente o requerente foi contratado na função de agente policial desde 2000, mas exercia, até dois meses antes da audiência de instrução, as funções específicas de investigador de polícia. Assim, comprovado o desvio de função, deve-se considerar seus reflexos, nos termos das Súmulas 378 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e 339 do Colendo Supremo Tribunal Federal: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

Não cabe ao Poder Judiciário que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Isto porque, por um lado, o desvio de função, embora irregular, não pode proporcionar vantagem indevida à administração, a qual tem obrigação de indenizar o funcionário pelo serviço efetivamente prestado. Neste sentido:

Reexame Necessário 990100383574 Relator(a): Magalhães Coelho Comarca: Carapicuíba Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 18/05/2010 Data de registro: 31/05/2010 Ementa: SERVIDOR PÚBLICO- Desvio de função - Exercício de funções inerentes a cargo diverso, que corresponderia a vencimentos superiores ao do cargo efetivo - Diferença salarial entre o cargo ocupado e o cargo efetivamente exercido - Vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública - Súmula 378 do STJ - Recurso oficial não provido.

Apelação 994050387871 (4453495600) Relator(a): Rui Stoco Comarca: São Paulo Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 17/05/2010 Data de registro: 27/05/2010 Ementa: Apelação Cível e Recurso "ex officio". Servidora Pública Municipal. Auxiliar de enfermagem. Desvio de função. Exercício de função

diversa (Assistente Social). Pretensão de pagamento de diferenças salariais durante o período em que trabalhou em desvio de função. Admissibilidade. Súmula 378 do STJ. Ação julgada procedente na origem. Recurso não provido.

Devido, portanto, o pagamento da diferença salarial, dos últimos cinco anos antes da interposição da ação até o final do período comprovado nos autos (dois meses antes da audiência de instrução), com os devidos reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, bem como recolhimento das diferenças previdenciárias e desconto de imposto de renda. Nesse sentido, os seguintes julgados:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente Policial que desempenha atribuições do cargo de Investigador de Polícia Desvio de função comprovado Diferenças salariais devidas (Súmula 378 do STJ). Verbas de natureza salarial Incidência de contribuição previdenciária e descontos de imposto de renda de rigor Jurisprudência do E. STJ. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação nº 1040605-11.2020.8.26.0053 - TJSP - Relatora Desembargadora Isabel Cogan - Julgamento: 14 de janeiro de 2022). Servidor Público Estadual - Diferenças salariais - Desvio de função - Ocorrência Agente policial que exerceu as funções correspondentes ao cargo de Investigador de Polícia - Indenização a fim de evitar o locupletamento indevido da Administração - Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação nº 1000836-66.2018.8.26.0699 - TJSP - Relator Desembargador Marrey Unt - Julgamento: 25 de janeiro de 2022).

Outrossim, tendo em vista o caráter exclusivamente indenizatório da condenação imposta, descabido que a ocorrência de desvio para período posterior à época da prova, bem como a incorporação de cargos ou o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, bem como inviável reflexos desta decisão sobre a aposentadoria do requerente. A jurisprudência:

Embargos Infringentes 994051072317 (4119655501) Relator(a): Reinaldo Miluzzi
Comarca: Campinas Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 22/02/2010 Data de registro: 22/03/2010 Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES - FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL - Aposentadoria - Cargo de professora III do Município de Campinas - Designação para ocupar o cargo de especialista de educação, nas funções de Vice-Diretora e Orientadora Pedagógica, em caráter de substituição, após concurso interno - Pretensão à incorporação do valor relativo ao aumento de jornada decorrente do exercício das funções de especialista de educação - Inadmissibilidade - Desvio de função - Afronta ao art. 37, II, da CF - Inexistência de direito adquirido à incorporação de cargos exercidos de maneira irregular - Impossibilidade de o Judiciário estender benefícios previstos na lei para servidores que ocupem outros cargos ou funções - Princípio da Separação de Poderes - Inexistência de indébito a ser restituído - Sentença de improcedência - Acórdão que acolheu, por maioria, o recurso de apelação da autora - Prevalência do voto minoritário - Embargos acolhidos

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a requerida ao pagamento da diferença salarial entre o cargo do autor de agente policial e o cargo de investigador de polícia, com reflexos em férias e décimo terceiro salário, bem como recolhimento das diferenças previdenciárias e desconto de imposto de renda, referente aos últimos cinco anos anteriores a interposição da ação (3 de novembro de 2015) até dois meses antes da data da audiência de instrução (10 de setembro de 2021), tudo acrescido de correção monetária pela Tabela Modulada da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo desde cada vencimento e juros de mora, nos termos do artigo 1º F da Lei 9494/1997, tomando como base o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação.

Ante a menor sucumbência do autor, condeno ainda a requerida ao pagamento de custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono do requerente, que fixo em dez por cento do valor da condenação. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da requerida, que fixo em R\$ 800,00, respeitado o disposto no art. 98 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à Segunda Instância para reexame.

P.R.I.

Jaú, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA